

第16問

甲は、Aを殺害しようと考え、景気づけに酒を飲んでから、A宅へ向かった。甲は、飲酒をすれば病的な酩酊状態に陥ることを自覚していた。甲は、A宅に立入り、Aに向けて拳銃を発射したところ、Aのみならず、その場にいたBにも当たり、Aを死亡させ、Bには全治約1か月の怪我を負わせた。その後、その場にあったAの財布を手に取り、A宅を出た。

甲は、A宅内に立ち入った時点ではいまだ意識があったが、その後、Aを殺害しBに怪我を負わせるまでの間、飲酒による酩酊状態にあり、心神喪失状態であった。

甲の罪責を論ぜよ。

第1 Aに対する罪責

- 1 まず、A宅内に侵入した時点で住居侵入罪（130前段）が成立する。
- 2 また、Aに対する殺人罪（199）の構成要件該当性が認められる。

もっとも、甲は、A宅内に立ち入った時点から、Aを死亡させBに怪我を負わせるまでの間、飲酒による酩酊状態にあり、心身喪失状態にあったのだから、Aを殺害した時には責任無能力状態にあったことになり、責任を問えないのではないかとと思われる（39 I）。

ここでは、いわゆる原因において自由な行為の問題が生じる（**論点** 原因において自由な行為  旧H13-1）。

この点については、大別して構成要件モデル、責任モデルがあり、各モデルの内部においてさらに対立があるものの、本問事情のもとでは、基本的にはどの立場に立ったとしても殺人罪の成立は認められるだろう。

- 3 続いて、Aの財布を手に取りA宅を出た点について、強盗殺人罪（240後段）の成否が問題となるも、Aを殺害した時点では、財物奪取の意思がなかったと思われるから、強盗殺人罪は成立しない。

そこで、窃盗罪の成否が問題となる。

いわゆる死者の占有について、判例（最判昭41.4.8【百選Ⅱ29】）は「被告人は、当初から財物を領得する意思は有していなかったが、野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであって、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である」と判示している（**論点** 死者の占有  司H29）。

この立場をとれば、本問でも窃盗罪が成立する。

第2 Bに対する罪責

殺人未遂罪（203、199）の成否が問題となるが、判例の法定的符合説（最判昭53.7.28【百選Ⅰ42】）に立つ限り、同罪の成立は認められるだろう（**論点** 具体的事実の錯誤  司H30,予H24,旧H5-2,H14-1）。

なお、甲は酒を飲んだ時点では、Aを殺害する意思であり、Bを加害する意思はなかったものの、これは有意な事情ではない。

 総合 88 頁  論証 33 頁

 総合 197 頁  論証 83 頁

 総合 37 頁  論証 7 頁

答案構成

第 1 A に対する罪責

1 住居侵入罪（130前段）成立

↓

2 殺人罪（199）の構成要件該当性あり

↓

甲はAを射殺した時点では心神喪失状態にあるから、39条1項により不可罰となるとも考えられる

↓

原因において自由な行為

↓

責任モデル

↓

あてはめ

↓

殺人罪成立

↓

3 窃盗罪（235）の成否

↓

死者の占有

↓

自ら被害者を殺害した者との関係では、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害するものと評価できる

↓

あてはめ

↓

A に対する窃盗罪成立

第 2 B に対する罪責

1 殺人未遂罪（203、199）の成否

↓

2 B に対する故意の存否

↓

法定的符合説＋数故意犯説

↓

3 B に対する殺人未遂罪成立

第 3 罪数

住居侵入罪をかすがいとして全体が科刑上一罪（54 I 後段）となる

第1 Aに対する罪責

1 甲がA宅内に立ち入った行為は、Aの殺害を目的とする、Aの意思に反する立ち入りであるから、「正当な理由がないのに、人の住居……に侵入し」たものとして、住居侵入罪（130条前段）が成立する。

2(1) 次に、甲が殺意を持ってAを拳銃で射殺した行為について、「人を殺した」ものとして、殺人既遂罪（199条）の構成要件に該当する。

一方、甲はAを射殺した時点では心神喪失状態にあるから、39条1項により不可罰となるとも考えられる。

しかし、かかる心神喪失状態は甲自身により引き起こされたものであって、甲には完全責任能力を問うべきである。そこで、そのための理論構成が問題となる。

(2) 責任の前提として責任能力が必要とされている根拠は、犯罪の結果が責任能力ある状態での意思決定に基づいて実現しているときに初めて非難が可能であるという点にある。

そうだとすれば、責任能力状態下における意思決定が結果行為まで貫かれており、結果が当該意思決定によって生じた場合には、全体として一個の行為であると認められるから、行為者はその行為全体について責任能力あるものとして責任を負ってしかるべきである。

具体的には、①責任能力状態下の自由な意思決定に基づく意思が連続しており、②原因行為・結果行為・結果に因果関係が認められる場合には完全な責任能力を問うことも可能と考える。

1

(3) 本件では完全な責任能力状態の下にAの殺害を決意し、その殺意を維持したまま射殺に及んでおり、殺害の意思がA殺害まで継続していると考えられる（①充足）。また、甲の飲酒、Aの射殺行為、Aの死亡との間には因果関係も認められる（②充足）。

したがって、39条1項の適用は排除されるから、甲には殺人罪が成立する。

3(1) 次に、甲はA殺害後、Aの財布（以下「本件財布」という。）を手に取り、A宅を出た点について、強盗殺人罪（240条後段）が成立するとも考えられる。しかし、「暴行」（236条1項）は財物奪取に向けられたものである必要があるところ、殺害行為の時点で甲に財物奪取の意思は認められないから、強盗殺人罪は成立しない。

(2) 一方、「他人の財物を窃取した」ものとして、窃盗罪（235条）の成立も考えられる。

もっとも、「窃取」とは他人の占有を排除して自己の占有に財物を移す行為をいうところ、甲が本件財布を手を取った時点でAは既に死亡しており、Aに占有が認められないのではないか。

確かに、死者には、占有を認めることはできない。刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であって、占有の事実と占有の意思から構成されるところ、死者には占有の事実も意思もないからである。

しかし、自ら被害者を殺害した者との関係では、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害するものと評価できる。

2

したがって、その者との関係においては、窃盗罪が成立し得る。

甲はAを殺害した直後に本件財布を奪取しており、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察すれば、甲との関係ではAの生前の占有が侵害されたと評価できる。

(3) 甲には故意(38条1項)及び不法領得の意思に欠けるところもないから、Aに対する窃盗罪が成立する。

第2 Bに対する罪責

1 Bに怪我を負わせた行為については、殺人未遂罪(203条、199条)が成立し得る。

甲は、拳銃を発射するという人の死の結果の現実的危険性がある行為を行っているものの、「これを遂げなかった」のだから、同罪の客観的構成要件該当性は認められる。

2(1) 一方で、甲は当初Aを殺害する意図を持って拳銃を発射し、結果Bにも怪我を負わせているところ、Bに対する故意を問うことができるか。

(2) 故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。そして、犯罪事実は、刑法上構成要件として類型化されており、かつ、各構成要件の文言上、具体的な法益主体の認識までは要求されていないと解されるから、認識した内容と発生した事実がおおよそ構成要件の範囲内で符合していれば犯罪事実の認識があったと考えられ、故意が認められると考える。

3

また、このように故意の対象を構成要件の範囲内で抽象化する以上、故意の個数は問題にならないと解する。

(3) 本件では、AとBは「人」という範囲内で符合しており、構成要件的な符合が認められる。

したがって、本件ではBに対する故意も肯定できる。

(4) そして、甲はAに拳銃を発射した時点において心神喪失状態にあるものの、上記のとおり、甲には完全な責任能力を問うことができる。

3 よって、Bに対する殺人未遂罪も成立する。

第3 罪数

以上より、甲には①A宅への住居侵入罪、②Aに対する殺人罪、③Aに対する窃盗罪、④Bに対する殺人未遂罪が成立し、①をかすがいとして全体として科刑上一罪(54条1項後段)となる。

以 上

4